

1500123-79.2022.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls. 41/42) revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas. Liberdade Provisória: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500123-79.2022.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-79.2022.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104321/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 24341565 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2104321 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2104321 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 18h20min, na Rua Plínio Gerduelo, esquina com a Rua Otaviano Pires, no bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 08 (oito) invólucros de "maconha", com peso bruto de 14,99 gramas (catorze gramas e novecentos e noventa miligramas), droga essa que

determina dependência física e psíquica (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória de fls. 21/24, fotografias de fls. 25/27 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado). Auto de prisão em flagrante delito e demais peças do inquérito policial (fls. 01/37). Em audiência de custódia realizada em 16 de abril de 2022, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 74/78). Notificado (fls. 123), apresentou Defesa Prévia (fls. 129/130). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022, oportunidade em que também houve a designação de audiência de instrução e julgamento (fls.131/132). Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 178/180-gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e pugnou pela procedência da ação para condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 178/180). Por sua vez, a douta defesa pugnou pela desclassificação do delito para a infração de porte de drogas para uso próprio, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pela fixação da pena do mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 186/187).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "no tempo e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, quando foi surpreendido por policiais militares. Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela cidade de Cerqueira César, quando avistaram dois indivíduos realizando uma espécie de transação no cruzamento das ruas Plínio Gerdulo, Otaviano Pires, local esse conhecido pelo comércio frequente de drogas. Ato contínuo, ao perceber que seria abordado pela Polícia Militar, o denunciado dispensou um invólucro contendo 08 (oito) tabletes de "Maconha" e correu. Durante a fuga, o denunciado pulou muros e cercas, vindo a sofrer quedas, bem como, dispensou outro objeto que não foi localizado. Após, o denunciado foi perseguido, capturado e abordado pelos policiais militares, que em busca pessoal, constataram que o acusado trazia consigo a quantia de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e este foi conduzido ao plantão policial de Avaré/SP. Anote-se que a natureza e a quantidade de droga apreendida 08 (oito) invólucros de "Maconha", com peso bruto de 14,99 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls.10/11, laudo de constatação provisória de fls. 21/24, fotografias de fls. 25/27), o local em que se desenvolveu a ação (já conhecido dos meios policiais como ponto de tráfico de drogas), a apreensão de quantia em dinheiro e as demais circunstâncias do caso apontam, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que os entorpecentes destinavam-se ao comércio ilícito."

Pois bem, a meu ver, os fatos narrados comprovaram-se em juízo, merecendo ser julgada procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), boletim de ocorrência de (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 21/24), pelo laudo toxicológico (fls. 145/147), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também restou comprovada e repousa, sem sombras de dúvidas, sobre o réu. A testemunha de acusação Emerson de Oliveira Gomes, policial militar, disse" que estavam em patrulhamento pelo rua Plínio Gerdulo, local conhecido pelo tráfico de drogas, momento em que viram dois indivíduos na rua. Viram o réu passar um objeto para outro rapaz, e este ao perceber a viatura policial saiu apressadamente do local. O acusado também se evadiu, dispensando algo ao chão e se dirigiu a um pasto com mato alto. Diligenciaram junto ao objeto que havia sido dispensado pelo réu e verificaram que se tratava de um invólucro contendo 8 porções de maconha.

Perseguiram o acusado que continuava correndo, quando ele pulou um muro de uma casa abandonada, sofreu uma queda , entretanto, prosseguiu correndo e dispensou outro objeto na mata. Porém, ao tentar pular outra cerca, ele caiu no chão e conseguiram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram a quantia de R\$280,00, divididos na

bermuda que ele usava. Questionado sobre a origem do dinheiro, Aparecido disse que era proveniente do tráfico e que estava fazendo "o recolhe dos moleques". Sobre o segundo objeto dispensado, o acusado afirmou ser dinheiro, mas não conseguiram encontrar, pois estava escuro e o local tinha o mato muito alto. "

Igualmente, o policial militar Ricardo Preinsack, sob o crivo do contraditório, reprisou a assertiva de seu colega. "Acrescentando que tiveram que imobilizar o acusado, pois este a todo momento tentava fugir".

O réu Aparecido de Almeida Rodrigues," relatou que é usuário de drogas e o dinheiro encontrado em sua posse, era proveniente da venda de seu aparelho celular. Afirmou que vendeu o aparelho por R\$300,00 e uma parte do dinheiro foi usado para comprar drogas."

Pois bem, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observo que a negativa do réu não encontra amparo nas demais provas do feito, sendo de rigor a condenação.

Nesse contexto, a versão do réu, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

In casu, a tipificação do crime de tráfico de drogas in casu extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida, do modo pelo qual estava acondicionada- em porções individuais a facilitar a comercialização e disseminação da droga, do local da apreensão-conhecido ponto de venda de drogas, bem como do dinheiro localizado, cuja origem lícita o réu não comprovou nos autos. Assim, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram sua responsabilidade criminal. Por isso, força convir que seus depoimentos merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os seus depoimentos prestados extrajudicialmente.

Destarte, os elementos probatórios coligidos estão a revelar iniludível traficância. Não se vislumbra qualquer interesse dos policiais em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais militares, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifo nosso)"

Neste ínterim, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte

Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125.

Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, inobstante o réu afirme que as drogas eram para uso próprio, em seu poder não foram encontrados apetrechos ou instrumentos utilizados para o consumo de drogas, ressaltando a finalidade mercantil dos entorpecentes. Por fim, as drogas foram encontradas em pequenas porções, forma de acondicionamento própria da venda "a varejo" de entorpecentes, restando devidamente demonstrada a finalidade comercial das drogas.

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Por derradeiro, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante sugerem que o réu estava traficando no local, tanto que os policiais militares foram unânimes em afirmar a existência de denúncias da traficância naquele local. Outro ponto a ser destacado é o fato de que o réu em nenhum momento comprovou satisfatoriamente exercer atividade lícita/emprego, portanto não teria dinheiro para adquirir as drogas, algo que também indica seu envolvimento com a criminalidade organizada. Além disso, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação e/ou perseguição. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que a ré praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, considerando a personalidade e comportamento social, revelados pelos registros criminais (F.A. e certidões a fls. 38/43), fixo a pena em seu patamar mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhetos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 41/42), portanto, majoro em 1/6 a pena anteriormente aplicada, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583-dis-multa. Na terceira fase, muito embora não exista nenhuma notícia e mesmo prova nos autos de que o réu pertencia a alguma associação criminosa, entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls. 41/42) revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Tal circunstância impede a aplicação

do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas. Liberdade Provisória: inadmissibilidade. Decisão que manteve a prisão. Participação em organização voltada para o tráfico de entorpecentes e grande quantidade de droga apreendida: circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06 e de substituição da pena: improcedência. Redução da pena inviável na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...]" (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12 – destaquei do original). Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º,

inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Cerqueira César.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque o réu respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber sentença condenatória. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA